

解除；

二、限梁某于本判决发生法律效力之日起十日内向黎甲返还定金5万元；

三、限梁某于本判决发生法律效力之日起十日内向黎甲支付违约金3万元；

四、驳回黎甲的其他诉讼请求。

黎甲不服一审判决，提起上诉。

广东省茂名市中级人民法院经审理认为：衡量违约金是否过高时，应查明实际损失数额，以确定基础标准，同时，还应结合合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量。在举证责任的分配上，守约方因更了解违约造成损失的事实和相关证据而具有较强的举证能力，因此，守约方应当对其遭受的可得利益损失总额、必要的交易成本承担举证责任。一审根据相关法律规定及案件具体情况，结合黎甲只是支付了5万元定金，尚未支付其他房款，梁某是愿意出卖房屋，只是由于特定因素影响过户，综合考虑黎甲的实际损失、梁某的违约程度，结合公平原则，并据此确定违约金数额，系依法行使自由裁量权，其确定的违约金数额亦未超出裁量幅度。因此，一审判决酌定涉案违约金为3万元，属于法官依法行使自由裁量权的结果，未造成双方当事人利益失衡，结果并无不当，应予以维持。

综上所述，黎甲的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。据此，广东省茂名市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

市场交易中，当事双方为保障合同的履行，往往会在合同中同时设置定金罚则和违约金条款等多重保险。定金和违约金均为对合同债权的一般担保，其区别在于，定金是在合同履行前由一方预先支付给对方的法定金钱担保方式，其担保功能不仅在于订约确认，亦在通过定金罚则实现最低限度之损害赔偿，且有不超逾主合同标的额20%的最高限额。违约金是在违约行为发生并明确违约责任时才给付，并且法律对双方约定违约金的数额没有限制。法院无权对定金责任予以酌减，而对于违约金，法院可基于当事人的抗辩行使自由裁量权，以违约实际损失为标准，对违约金予以适当调整。《中华人民共和国民法典》第五百八十八条第一款规定了定金和违约金的适用关系。合同当事人既约定了定金，又约定了违约金，在当事人不存在明确的特别约定的情况下，如果一方违约，对方当事人可以选择适用违约金或者定金条款，但二者不能并用，权利人只能择一主张。司法实务中，基于定金和违约金不同的规则可能导致不同的判决结果，对原告诉讼策略的选择提出了考验。

于是一种观点认为，原告在选择起诉主张定金罚则或违约金赔偿时，通常选择按约赔偿获益更多者。但由于法律赋予了违约方对违约金的酌减请求权，而该请求权属于法定形成诉权，只要违约方提出了约定的违约金过高的抗辩主张，法院即有权依据实际损失调减违约金数额，最终可能导致守约方选择主张违约金所得低于主张定金罚则所得的情况。因此，法院在酌减违约金数额时，应当将当事人主张定金罚则可得的预期利益作为考量因素之一。这同样是由于实践中，法院在确定违约金数额是否合理时只能以违约损失为参照，但实际的违约损失常常无法或很难准确估计，只能由法官自由裁量，而这一结果对于原告是难以预测的，无疑不合理地增加了权利人的诉讼策略和选择风险。

笔者认为，意思自治和公平原则均是民法领域的基本原则，这体现在法律尊重民事主体在一定范围内基于个体的自由意志进行民事活动、作出民事法律行为，但意思自治也存在边界和限制，公平原则就是其一。定金与违约金均为债的担保，同时也是双方当事人意思自治的体现。但法律仅赋予了违约金酌减

的规则，而违约金酌减规则背后体现的是公平原则，对定金过于宽泛地适用一定程度上阻碍合同实质公平的实现。

首先，从立法目的来看，定金的惩罚性规则与违约金以补偿性为主、惩罚性为辅的性质相较，定金责任的惩罚性色彩通常比违约金责任更浓厚。这就决定了如果在违约金的司法酌减中对定金责任予以考量，增加定金的潜在适用范围，固然充分保障了守约方的诉讼利益，但就实际结果来说，可能给予了守约方远超实际损失的利益，过分加重了违约方的负担。

其次，从定金不得超过主合同标的额20%的设立规则来看，法律已经通过对定金的数额进行限制，将定金的惩罚性限制在一定范围内，以保证双方的公平。但在极端情况下，尤其是标的额较大的房屋买卖合同以及大宗商品贸易合同中，即使对定金施加20%的限额，仍存在过分高于实际损失的情境。定金罚则对于违约方来说是一种预定的而非现实性的负担，由于人的理性是有限的，各类事务、情况也是在不断变化发展中的，当事人可能无法全然事先预知，合理安排未来的事务以保证合同的顺利履行。因此，在造成实质不公平的场合，法官在行使自由裁量权时，应当在法律赋权的范围内尽可能地平衡双方利益，而非单一考虑原告的诉讼利益。

最后，从权利义务对等的立法技术考量，根据《中华人民共和国民法典》第五百八十八条第二款的规定，定金不足以弥补一方违约造成的损失，对方可以请求赔偿超过定金数额的损失。法律赋予了非违约方在定金低于实际损失的情况下超出定金数额的赔偿请求权，却未赋予违约方在定金高于实际损失的情况下降低定金数额的抗辩权，这已经是法律对于主张权利一方的优待，况且守约方对其实际损失的情况是最为了解的，其作为原告的证据准备条件也是最充分的，故而由其承担相应的诉讼风险也不为过。

编写人：广东省茂名市中级人民法院 江
怡静

房屋销售人员的承诺构成要约，开发商 违反相关承诺应承担违约责任

—— 张某诉某置业公司房屋买卖合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第二中级人民法院(2023)京02民终11238号民事判决书

2. 案由：房屋买卖合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 张某

被告(上诉人): 某置业公司

【基本案情】

2022年6月19日，张某与某置业公司签订《北京市商品房认购书》，约定由原告购买401房屋，总购房款为466万元，原告已全额支付购房款。在原告购房前，原告多次通过微信群聊等方式询问销售人员房屋内相连两间卧室的隔断墙面是否为承重墙、是否可以打通，并表示如果不能打通将不会购买该房屋。被告售楼处工作人员邓某答复称该隔断墙面为非承重墙可以打通。原告购买该房屋后装修施工时被施工人员告知该墙体为承重墙，后向开发商确认，该墙体确实为承重墙，故起诉要求某置业公司支付其违约金20万元。

某置业公司称，双方签订的合同中，原告承诺对涉案房屋状况知悉且了解， 承重墙是大众的一般认知，买受人未尽到审慎义务和全面了解的义务。该面墙 是不是承重墙，并不决定原告买房的意愿，原告购房的主要目的是居住，改变

三、商品房销售合同纠纷 247

墙体仅是改变布局，并不影响其能否居住，售楼处工作人员邓某为与被告合作的房产经纪公司的员工，认可其在被告售楼处进行房屋销售，但认为邓某不具有承诺墙体性质的权限，其承诺是无权代理，被告不予追认。

【案件焦点】

1. 房产销售人员对墙体性质作出承诺，其行为性质如何认定，是否需要审